

1500872-55.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... fls. 119/121. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Mario Alessandro Camolesi, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram acusado em atitude ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500872-55.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000632

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151696/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 18316547 - 02º D.P. PIRACICABA, 2083/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2151696 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON GABRIEL ALVES DOS SANTOS

Aos 22 de fevereiro de 2022, às 15:45h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: MAICON GABRIEL ALVES DOS SANTOS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM MARIO ALESSANDRO CAMOLESI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM DOUGLAS MACHADO COUTINHO - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PM MARIO ALESSANDRO CAMOLESI.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM DOUGLAS MACHADO COUTINHO, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM

DOUGLAS MACHADO COUTINHO , o que foi homologado pela MM^a. Juíza. Após, o réu MAICON GABRIEL ALVES DOS SANTOS foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "Maicon Gabriel Ales dos Santos , já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 147), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 151/155), sendo a denúncia recebida (fls. 156/158). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi declarado revel. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 pelas fotografias de fls. 13/14 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 119/121. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Mario Alessandro Camolesi, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram acusado em atitude suspeita, parado em um ponto da via. Reconheceu o réu, que já era conhecido de outras abordagens, e estranhou ele estar ali naquele local. Ante as atitudes suspeitas, resolveram aborda-lo. Em busca pessoal, localizaram no bolso de sua bermuda seis microtubos de cocaína e R\$ 277,00 em notas variadas. Indagado, o acusado confessou que estava no local comercializando drogas, eis que estava desempregado, já tendo faturado até aquele momento mais de trezentos reais, e inclusive já tinha gasto uma parte desse dinheiro com algumas meninas. Em buscas pelo local onde o réu estava, encontraram, escondido debaixo de uma pedra, a cerca de cinco metros do acusado, mais 08 microtubos contendo cocaína e três invólucros de maconha, tendo o acusado assumido a propriedade também daqueles entorpecentes. No mesmo sentido foram as palavras do policial militar Douglas Machado Coutinho, ouvido apenas em fase policial. Por fim, o réu negou o trafico, dizendo que estava no local para comprar drogas para seu uso. Disse que os "moleques" que lhe venderam as drogas correram, e ele foi abordado. Disse que o troco que os "moleques" estavam de fato em notas diversas, sendo que as drogas que comprou totalizaram R\$ 75,00 e entregou como pagamento ao suposto traficante uma nota de cinquenta e uma de cem reais. Sua negativa, entretanto, não tem como prevalecer, eis que restou isolada no álbum probatório. Primeiro, tem-se que a "a conta" dos valores alegados pelo réu não batem, eis que se tivesse comprado R\$ 75,00 em drogas não teria porque entregar como pagamento uma nota de cem e outra nota de cinquenta reais. Ademais, é certo que ele tinha em seu poder R\$ 277,00 em notas miúdas e trocadas, não tendo conseguido justificar a contento tal fato. Por outro lado, é certo que os policiais ouvidos tanto na fase judicial quanto inquisitiva foram coesos ao afirmar que o réu encontrava-se parado na via publica, em ponto conhecido como sendo de trafico de drogas, trazia consigo parte dos entorpecentes apreendidos e a outra partes estava escondida embaixo de uma pedra a cerca de cinco metros do local onde estava o réu. . Ainda, afirmaram que em seu poder foi apreendida 277,00 em notas diversas, e que ele confessou a pratica do trafico no local, justificando que estava desempregado. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,

mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, ante a prova oral produzida, bem como a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado e as circunstâncias em que foi ele flagrado, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, haja vista primariedade do acusado. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a ser reconhecidas. Na terceira fase, em que pese a primariedade do acusado, uma vez que apresenta ele várias passagens pela Vara da Infância e Juventude enquanto adolescente, inclusive por tráfico de drogas, tem-se ser inaplicável o art. 33, §4º da Lei de Drogas, eis que tal circunstância indica que a venda de drogas não é fato isolado na sua vida, ao contrário, denota que faz ele há tempos dessa conduta ilícita ato corriqueiro em sua vida. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 277, 00 (duzentos e setenta e sete reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial os entorpecentes localizados em poder do réu, são ilícitas porque foram constituídas a partir de uma busca pessoal irregular. Com efeito, em relação à busca pessoal, é de se observar que ela não observou os requisitos previstos no artigo 240 do Código de Processo Penal. Isso porque os Guardas Municipais declararam que fizeram a abordagem do réu porque ele "estava em atitude suspeita", sem fossem visualizadas condutas prévias que indicassem o seu envolvimento no comércio de entorpecentes ou que existissem sequer denúncias a respeito do acusado. Ora, evidente, portanto, que não havia qualquer suspeita da prática do tráfico de drogas a ensejar a busca pessoal, revestindo-a, portanto, de ilegalidade. Nesse sentido, observe-se o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. 3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, conseqüentemente, determinar o trancamento da ação penal. (RHC 142.588/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). Todavia, caso sejam rejeitadas todas as preliminares suscitadas pela Defensoria Pública, QUANTO AO MÉRITO, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório

robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Mario, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o acusado no final da rua, parado. A rua termina em uma área de mata e, quando os indivíduos avistam a viatura, eles correm. Porém, o réu não correu. Reconheceu o acusado parado no local porque já o abordou em outra ocasião e em outro local, por isso resolveu abordá-lo novamente. Em poder do réu, encontraram algumas porções de cocaína, além de R\$ 277,00 em dinheiro. O acusado confessou informalmente que estava traficando e disse que estava passando necessidades financeiras. O acusado assinou o BOPM com essa versão. Ele disse também que tinha gastado parte do dinheiro com algumas “meninas” que estavam com ele antes de ser abordado. Em buscas pelas redondezas, encontraram o restante das porções de cocaína, idênticas às que estavam com o réu, e porções de maconha. O acusado admitiu que as drogas nas imediações pertenciam a ele. O acusado estava sozinho. O local é conhecido como ponto de tráfico. Foi apreendido dinheiro em poder do réu, em notas trocadas. Eram R\$ 277,00. O réu, em interrogatório, declarou que foi comprar entorpecentes para seu consumo pessoal. Enquanto estava comprando, a viatura chegou e os traficantes correram. O dinheiro era proveniente do seu trabalho com seu padrasto. Na verdade, portava cocaína e maconha. Foi abordado por outra viatura. Os traficantes correram e não correu porque não tinha motivo para se evadir. Disse aos Policiais que era usuário de drogas. Pagou R\$ 75,00 pelos entorpecentes. Em momento algum disse que estava “com meninas”. Se assinou alguma coisa, assinou sem ler. Já teve envolvimento com o tráfico de drogas no passado, enquanto adolescente. Chegou até a ser “disciplina” do bairro. O Policial que prestou depoimento o conhecia. Ele disse que se o réu dissesse onde estava uma pessoa envolvida com o PCC, seria liberado. Porém, não podia dizer isso, pois sofreria represálias. Não era do PCC, trabalhava como “apoio” aos integrantes do bairro. Porém, tinha abandonado o crime, estava vivendo em união estável e trabalhando. As drogas encontradas embaixo da pedra não lhe pertenciam. Elas pertenciam aos traficantes, eles deixam as drogas nesses locais para facilitar a intermediação com os usuários. As drogas que eram suas eram os 06 pinos de cocaína e as 03 porções de maconha. Estava em outro bairro porque, no Santa Terezinha, os Policiais o abordavam constantemente e não aguentava mais. Atualmente, está preso por tráfico de drogas. Pagou R\$ 75,00 pelas drogas. Entregou a eles uma nota de R\$ 50,00 e uma de R\$ 100,00, recebendo o troco em dinheiro. Excelência, o acusado, como visto, nega a prática do tráfico de drogas. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque as provas reunidas pela acusação se resumem às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do réu. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: “Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão

sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais, nenhum ato efetivo de comércio foi avistado antes da abordagem, além de não terem sido apresentados outros indivíduos como eventuais compradores das substâncias entorpecentes e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, boa parte dos entorpecentes não estava sob a posse direta do réu, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Ademais, a mera afirmação de que o local dos fatos seria um ponto de tráfico não acarreta a presunção de que o acusado estaria envolvido com o crime, eis que, nesses locais, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários dessas substâncias. Ressalta-se, também, que ocorreram certas divergências no depoimento dos Policiais, haja vista que, em solo policial, eles afirmaram que o réu, informalmente, teria mencionado que gastou parte do dinheiro que teria recebido com alimentos e bebidas, enquanto em Juízo ele mencionou que parte dos valores teriam sido gastos "com umas meninas". E a suposta confissão informal do acusado, além de constituir uma circunstância aberrante, que destoa do ordenamento jurídico, não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. [16:55] Rafael Bresciani Marracini Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra "dedicação às atividades criminosas", faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: "Artigo 2º - Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente

Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal); (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista que ele foi solto durante o processamento do feito e inexistente fato concreto que autorize, neste momento, a decretação de sua prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

“Vistos.

MAICON GABRIEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/03, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de junho de 2021, por volta das 14h00, na Rua Querubim Sampaio, nº 282, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 14 (quatorze) microtubos tipo eppendorf de cocaína, pesando cerca de 21,6g (vinte e um gramas e seis decigramas), e 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 14,1g (quatorze gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram o acusado parado em um ponto da via, em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, no bolso de sua bermuda, os policiais localizaram 06 (seis) microtubos de cocaína e a quantia de R\$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) em

dinheiro, em notas variadas. Indagado, MAICON GABRIEL confessou informalmente que traficava no local, eis que estava desempregado, e que já havia faturado mais de trezentos reais com a conduta ilícita, tendo comprado refrigerantes e doces antes de ser abordado. Em buscas pelos arredores do local onde o réu estava parado, os policiais localizaram, embaixo de uma pedra, mais 08 (oito) microtubos de cocaína e 03 (três) porções de maconha, cuja propriedade o réu assumiu e confirmou que também se destinavam à venda.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 147) e apresentou defesa preliminar (fls. 151/155), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia em 20.09.2021 (fls. 156/158).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. O E. Supremo Tribunal Federal, a fim de coibir excessos e arbitrariedade, assentou entendimento segundo o qual o ingresso em residência, sem autorização do morador e sem ordem judicial, para ser lícito, demanda quadro de fundada suspeita de situação de flagrante delito. Logo, os policiais somente podem adentrar em residência se tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime, impondo-se controle jurisdicional posterior da diligência para se definir se a ação policial era justificada ou não.

Confira-se, sobre o tema, o julgado em que assentado o entendimento do Pretório Excelso: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).

Esse mesmo entendimento pode ser aplicado à busca pessoal, face ao que dispõe o art. 240, § 2º, do CPP.

No caso em tela, os policiais informaram que avistaram o réu, já conhecido nos

meios policiais em razão do envolvimento com o tráfico, em local conhecido como ponto de venda de drogas

A abordagem do acusado não constituiu, portanto, ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelas fotografias de fls. 24/25 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 119/121, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que foi até o local dos fatos para comprar entorpecente. Alegou que, quando apareceu a viatura, os meninos correram e ele ficou no local, pois não devia nada. Asseverou que tinha R\$ 350,00 e mais alguns trocados, que tinha recebido em seu trabalho, e gastou R\$ 75,00, comprando seis porções de cocaína e três de maconha. Atestou que o local era realmente ponto de tráfico e os policiais encontraram drogas embaixo de uma pedra, mas foram deixados ali pelos moleques que estavam vendendo. Informou que, quando adolescente, entrou para a vida do crime, roubava, traficava e era “disciplina” no bairro Boa Esperança, como apoio dos integrantes do PCC, tanto que o policial Camolesi já o conhecia, mas engravidou sua mulher e mudou de vida.

A prova dos autos, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o policial militar Mario relatou que estavam em patrulhamento e avistaram o réu, parado no final da rua. Disse que o local já era conhecido como ponto de tráfico e dá para uma mata, para onde geralmente as pessoas correm.

Afirmou que o réu ficou parado no local e, então, decidiu abordá-lo, pois já o conhecia da época em que era adolescente e o havia abordado diversas vezes em outro bairro, estranhando o fato de ele estar naquele local. Disse que, em revista pessoal, encontraram seis eppendorfs de cocaína com o réu e R\$ 277,00 em notas trocadas. Indagado, o réu disse que estava desempregado e, em Santa Terezinha estava sujo para ele, razão pela qual estava naquele local, traficando. Acrescentou que o réu falou que tinha gasto certa quantia em dinheiro com meninas que estavam com ele e, em razão disso, fizeram vistoria no local e encontraram mais invólucros de cocaína idênticos aos que estavam com o réu, totalizando quatorze, e três porções de maconha. Atestou que o réu admitiu a posse de toda a droga e que estava traficando.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar

Douglas.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais militares terem visualizado em réu em atitude suspeita, parado na via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, vindo a localizar seis porções de cocaína e R\$ 277,00 no bolso da bermuda dele, além de três porções de cocaína, embaladas de maneira idêntica às encontradas na

sua posse, e três porções de maconha escondidas debaixo de uma pedra a poucos metros do local da abordagem, conduzem à certeza quanto a autoria.

Prosseguindo, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico, deixam evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 00038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Logo, de rigor a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, valendo anotar que, para a caracterização do tráfico, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo, guarde ou tenha em depósito a substância entorpecente.

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, as atenuantes da menoridade e da confissão não podem reduzi-la. Não há causas de aumento e o acusado não faz jus à redução da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. O § 4º do art. 33, tem a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo. O redutor incide na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (cf. Apelação nº 990.09.155655-6, Rel. Des. Luís Antonio Cardoso, j. 29.6.2010).

Na hipótese, o réu teve passagens pela prática de infração equiparada ao tráfico, enquanto menor, sendo-lhe impostas medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação (autos 0001636-50.2016 e 0013905-58.2015, ambos da Vara da Infância e Juventude local - cf. certidão de fls. 116/117), o que não permite concluir que o réu é traficante meramente ocasional e, portanto, merecedor da redução da pena.

Sobre o tema, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Apelação nº 0000491-64.2016.8.26.0125, Rel. Des. Ivan Sartori, j. 23.06.17, no qual é invocado o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos 'servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza' e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a

incidência do benefício. 2. Ordem denegada" (HC 121509/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 29.03.2010).

Não é demais anotar que o próprio réu afirmou que vivia no mundo do crime, roubava e traficava, bem como exerceu função de disciplina no bairro em que morava, apoiando integrantes de organização criminosa.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Porém, porque respondeu solto ao processo, o réu poderá assim apelar.

Demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, deve ser declarado seu perdimento.

4. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando MAICON GABRIEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial fechado e reconhecido o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 21/02/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]